

1500892-41.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... era de que havia denúncia de prática do crime de tráfico de drogas. Nenhuma outra diligência foi realizada de forma a verificar tal ocorrência.

Portanto, não se pode falar que havia indícios concretos da prática do crime por parte do suspeito. A única informação que se tinha era o nome e de que ele já tinha sido condenado por crime de tráfico de drogas, nada mais.

Sobre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500892-41.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500892-41.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2062797/2021 - 04º D.P. SANTOS, 16592132 - 04º D.P. SANTOS, 97/21/214 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ÉRISON DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

DANIEL ÉRISON DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Conforme narra a denúncia, no dia 04 de março de 2021, por volta das 14 horas e 20 minutos, na Avenida Conselheiro Nébias, nº 150, nesta cidade e comarca, o acusado possuía um revólver marca Rossi, calibre 38, municiado com quatro cartuchos do mesmo calibre. A numeração dessa arma estava raspada. O acusado agia em desacordo com a lei e o regulamento.

Em circunstâncias não esclarecidas, o acusado obteve o revólver, de numeração raspada, e as munições. Então, ele deixou essa arma de fogo municiada no quarto onde reside, dentro de um imóvel destinado à habitação coletiva.

No dia do crime, policiais militares foram até o endereço para apurar notícia que apontava nominalmente o acusado como suposto traficante de drogas. Eles viram o acusado na frente do imóvel.

Indagado, ele negou ser traficante de drogas, mas respondeu possuir a arma e as munições, sem qualquer autorização legal. Com a permissão do acusado, os policiais realizaram busca no quarto por ele habitado e apreenderam o revólver municiado.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 06/08). Auto de exibição e apreensão (fls. 09).

A denúncia foi recebida em 31/03/2021 (fls. 95).

O réu ofertou defesa prévia (fls. 122/127) e foi citado (fls. 161).

Lauda pericial da arma apreendida (fls. 128/132).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público, preliminarmente, alegou não ser caso de celebração de acordo de não persecução penal, visto que o acusado é reincidente em crime doloso. No mérito, pugnou pela procedência da ação penal. Aduziu que o depoimento dos policiais foi suficiente para esclarecer toda a dinâmica dos fatos. Alegou que o encontro da arma foi realizado com a colaboração do acusado.

A D. Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal. Alegou que apesar de os policiais terem afirmado que o acusado franqueou a entrada na sua residência, isso não corresponde à realidade, conforme se denota do depoimento do acusado em seu interrogatório. Os depoimentos das testemunhas de defesa corroboram a alegação do acusado. Desta forma, os policiais militares jamais poderiam ter entrado em sua residência sem mandado de busca e apreensão. Portanto, diante da coação exercida pelos policiais, ainda que indiretamente, postulou pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente declaração da ilicitude das provas que decorrem da busca ilegal realizada pelos policiais. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo, com compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Desta forma, requereu a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de o acusado recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, cumpre salientar que na audiência de instrução e julgamento, após a oitiva das testemunhas e da realização do interrogatório do réu, as partes foram indagadas sobre a necessidade de produzir outras provas.

Conforme se depreende do termo de audiência de fls. 195, as partes afirmaram que não possuíam outras provas a produzir, oportunidade em que a instrução processual foi encerrada e foram realizados os debates orais.

Desta forma, verifico que a petição de fls. 197/201 foi juntada de forma intempestiva, uma vez que foi apresentada após o encerramento da instrução, a qual ocorreu com a anuência do I. Defensor.

Portanto, não há como conhecer da mencionada petição, visto que ela foi apresentada após o encerramento da instrução e dos debates orais, encontrando-se, deste modo, preclusa a produção de qualquer outra prova.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11. 343/06 – IMPOSSIBILIDADE (...) Deveras, encerrada a oitiva das testemunhas e já interrogado o acusado, sendo declarado por este Juízo em audiência que as partes não tinham novas provas a produzir (o que não foi impugnado), encerrando-se a instrução em razão de não haver nova diligência probatória a ser realizada, tudo sem que houvesse impugnação acompanhada de requerimento de produção de novas provas na audiência realizada (tudo conforme se verifica do termo de audiência de fls. 249-251 e da gravação do que restou deliberado no curso da respectiva audiência), verifica-se que se encontra preclusa a oportunidade para produção de novas provas (...)” (TJ-SP - APR: 15020764220208260544 SP 1502076-42.2020.8.26.0544, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 18/02/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/02/2022).

Por estas razões, passo a proferir sentença sem considerar a petição (fls. 197/201) e os documentos com ela apresentados.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade delitiva do crime imputado ao acusado não restou satisfatoriamente

comprovada.

A testemunha de acusação RODRIGO PAES DE LIRA, policial militar, afirmou que teve conhecimento através de uma denúncia anônima, que o acusado possuía drogas e armas, além de pertencer a uma organização criminosa. Chegando no local dos fatos, deparou-se com o acusado descendo do imóvel, indo em direção a sua entrada. Abordou o acusado na porta do seu prédio. Indagado sobre a posse de drogas e armas, o acusado afirmou que não possuía drogas, porém, admitiu possuir uma arma para sua defesa, a qual se encontrava guardada em seu quarto. Nesta oportunidade, com a autorização do acusado, adentrou em seu apartamento, encontrando um revólver municiado, com a numeração obliterada. Em razão do armamento encontrado, o acusado foi encaminhado à delegacia. Afirmou que foi até o local dos fatos com o apoio de outras viaturas. Não encontrou nenhum apetrecho característico do tráfico de drogas. Contou que os policiais que o acompanharam realizaram a busca em outras portas do imóvel. Não conhecia o acusado antes dos fatos.

A testemunha de acusação DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, policial militar, afirmou que tomou conhecimento por um Disque Denúncia, que no local dos fatos drogas estavam sendo traficadas, bem como que existia armamentos no local. Relatou que teve conhecimento do nome do acusado através das informações colhidas no Disque Denúncia. Chegando ao local, foi até um comércio, onde um jovem indicou a residência habitada pelo acusado. Encontrou o acusado na porta de sua residência, realizando a sua abordagem. Indagado sobre a posse de drogas e armas, o acusado afirmou que guardava um revólver para sua defesa, em baixo do seu colchão, porém negou ter qualquer substância ilícita. Relatou que adentrou na residência do acusado e encontrou em sua posse um revólver, calibre 38, municiado com quatro munições, com a numeração suprimida. Não encontrou qualquer apetrecho característico do tráfico de drogas. Contou que chegou até o local dos fatos com uma equipe policial contendo duas viaturas. Não conhecia o acusado antes dos fatos.

A testemunha de defesa SARAH SÉFORA DE SOUSA AGOSTINHO, afirmou que o acusado é o seu tio. Relatou que no dia dos fatos, estava fazendo almoço na cozinha, quando ouviu o barulho dos policiais entrando em sua casa. Neste momento, o acusado estava em seu quarto. Cerca de dez policiais entraram no local dos fatos armados. Contou que os policiais procuraram por todo o imóvel, não encontrando drogas no local. Não soube informar se algum armamento foi encontrado no quarto do acusado.

A testemunha de defesa JULIANA PEREIRA, afirmou que conhece o acusado em razão da proximidade do seu bar com o estabelecimento de Damião, seu compadre. No dia dos fatos, estava saindo do bar, quando avistou as viaturas e algumas motos da polícia militar estacionando. Posteriormente, observou os policiais arrombando a porta do imóvel do acusado.

A testemunha de defesa SUELI MARQUES DA SILVA, afirmou que trabalha na loja Ceará Colchões, localizada em frente ao bar e a residência do acusado. A distância entre a loja que trabalha e a residência do acusado é de cerca de três metros. No dia dos fatos, estava dentro da loja, quando se assustou com as diversas viaturas e motos da polícia militar, as quais estacionaram em frente à mencionada loja de colchões. Relatou que os policiais forçaram a sua entrada, arrombando a porta da casa do acusado. Posteriormente, observou os policiais descendo com o acusado algemado.

O réu DANIEL ÉRISON DE SOUSA, interrogado, afirmou que parte dos fatos são verdadeiros. Admitiu ter a posse do revólver encontrado pelos policiais. Assim que foi indagado pelos policiais, prontamente informou sobre a existência do mencionado revólver. Apesar de ter passagem por tráfico, afirmou que não integra organização criminosa, bem como que saiu pela porta da frente do sistema prisional. Relatou que adquiriu a arma com um senhor, que sempre ia até o seu comércio oferecê-la, apenas para a sua defesa. O revólver estava guardado em seu guarda-roupa e não em baixo de sua cama, como relatado pelos policiais. Afirmou que estava no seu quarto quando ouviu um barulho na porta, momento em que os policiais forçaram a entrada em sua casa. Relatou que os policiais invadiram a sua residência, arrombando a porta sem apresentar ordem judicial.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

O presente processo iniciou com a prisão em flagrante do acusado Daniel Erison de Souza, sob o fundamento de prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV

da Lei nº 10.826/03, em razão de ter sido localizada em sua residência uma arma de fogo com a numeração raspada.

Disseram os policiais que receberam denúncia anônima através do canal Disque Denúncia, indicando que pessoa de nome "Daniel Erison de Sousa" estaria traficando na Avenida Conselheiro Nébias 150. Por esta razão, rumaram naquele sentido e surpreenderam o acusado deixando o imóvel. Na abordagem nada de ilícito foi encontrado. Ele foi informado da denúncia anônima e, se identificou como sendo Daniel, mas disse não estar traficando. Todavia, afirmou que possuía arma de fogo em seu poder para sua segurança. Disseram, ainda, que o acusado deu permissão para eles ingressarem em sua residência, local onde encontraram o armamento apreendido. Em juízo, a versão dos policiais Rodrigo e Daniel apresentou divergência em relação àquela prestada na fase policial, pois afirmaram que a denúncia também dizia que "Daniel Erison de Sousa" além de praticar o crime de tráfico de drogas, também armazenava arma de fogo, o que não disseram na versão prestada na fase policial. O acusado, em seu interrogatório na fase policial e, também judicial, confirmou a posse da arma de fogo localizada. Contudo, destacou que não foi abordado na rua, mas no interior de sua residência e, que em nenhum momento deu permissão para o ingresso dos policiais. Muito pelo contrário. Foi surpreendido na casa por policiais militares do BAEP, sob a alegação que ali estariam averiguando a uma denúncia que versava sobre o comércio ilegal de drogas.

Não se pode olvidar que os depoimentos das testemunhas de defesa Juliana e Sueli, corroboram a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que os policiais forçaram a entrada em sua residência.

Diante da controvérsia quanto à permissão do acusado para que os policiais entrassem em sua residência, impõe-se a análise da validade da busca e apreensão realizada.

A busca e apreensão domiciliar é regida, constitucionalmente, pelo disposto no artigo 5º, XI, da CF/88: "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial."

O primeiro ponto a se analisar, portanto, é a hipótese de ingresso com consentimento do morador e, para tanto esse consentimento deve ser válido.

Guilherme Madeira Dezem bem destaca: "O consentimento do morador deve ser analisado com cautela. Assim, por se tratar de exceção constitucional precisamos lembrar que a qualquer tempo poderá ser retirado o consentimento. (...) De nada adianta a Constituição Federal erigir um castelo em torno do domicílio, se este castelo pode ser aberto de qualquer forma, pois seus portões são de papelão" (Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p. 834).

Na mesma linha, o E. Min. Rogério Schietti Cruz bem destacou: "O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: 'O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!'" (STJ, T6, HC 598051/SP, DJE 02.03.21).

Nesse raciocínio, comporta verificar que diante controvérsia em relação à autorização do morador (no caso o acusado) para ingresso dos policiais em seu domicílio, deve vigorar o princípio do in dubio pro reo, ou seja, deve ser considerado que o acusado não é obrigado a produzir prova contra si próprio (nemo tenetur se detegere).

E, segundo julgado do E. STJ (HC 598051/SP), o ônus da prova da legalidade da entrada no domicílio é do Estado.

No mesmo sentido as lições de Renato Brasileiro de Lima: "Para validar o ingresso de agentes estatais no interior da casa e subsequente busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Na visão dos Tribunais Superiores, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se,

sempre que possível, testemunhas do ato. (...) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade (...)." (Manual de Processo Penal, Editora JusPodium, 10ªed. , p. 696).

Portanto, considerando a inexistência de qualquer comprovação da autorização do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência e, diante da versão por ele apresentada, a qual foi corroborada pelas testemunhas Juliana e Sueli, a partir daqui, se analisa o flagrante considerando que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado ocorreu sem a sua permissão e, por conta disso, deve ser analisado a situação do flagrante de crime permanente, pois, no caso, o crime de posse da arma de fogo com numeração raspada se protraiu no tempo, ou seja, a ofensa ao bem jurídico protegido remanesceu durante todo o período de tempo em que referida arma de fogo permaneceu no imóvel do acusado.

Desta forma, passa-se a analisar a busca e apreensão, sem mandado judicial e sem autorização do acusado para ingresso na sua residência, mas sob a alegação de se estar diante da segunda hipótese de permissão constitucional para a violação do domicílio, ou seja: em caso de flagrante delito.

E, sob esse aspecto, tem-se que a medida também se mostrou ilegal.

No caso sob análise, segundo os policiais, na fase policial, o argumento era de que havia denúncia de prática do crime de tráfico de drogas. Nenhuma outra diligência foi realizada de forma a verificar tal ocorrência.

Portanto, não se pode falar que havia indícios concretos da prática do crime por parte do suspeito. A única informação que se tinha era o nome e de que ele já tinha sido condenado por crime de tráfico de drogas, nada mais.

Sobre a matéria o C. STF já pacificou: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Essa a orientação do Plenário, que reconheceu a repercussão geral do tema e, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia, à luz do art. 5º, XI, LV, LVI, da CF/1988, a legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado de busca e apreensão" (STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).

Analisando a situação, Guilherme Madeira Dezem pondera: "O problema reside na análise dos motivos que levaram à entrada do domicílio sem mandado. Não se pode fazer aqui o raciocínio do resultado para a ação desenvolvida, valendo-se do resultado como legitimador da conduta. Esse raciocínio pernicioso põe ao chão a proteção constitucional do domicílio." (Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p. 836).

Por conseguinte, o fato de ter sido localizado algo ilícito e que configura crime permanente no domicílio não significa, necessariamente, que a conduta desenvolvida pelos agentes foi correta. Do mesmo modo que, não localizar nada não significa que a conduta dos policiais foi ilegal.

Destaca o citado doutrinador: "O que precisará ser feito pelo Poder Judiciário é ignorar o resultado e analisar os motivos dados pelos agentes para a entrada no domicílio, somente assim teremos a análise concreta dos motivos que ensejaram a entrada no domicílio e poderá haver o concreto controle judicial" (Dezem, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p.836).

Assim sendo, no caso concreto em análise, tem-se que a conduta dos policiais de ingresso forçado no domicílio do acusado foi ilegal, justamente porque não tinham motivos concretos mínimos para justificar o ingresso sob o argumento de ocorrência de crime de tráfico de drogas no local.

Ficou evidente pela instrução processual, que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado não foi precedido de mínima investigação para averiguar as informações apontadas na denúncia.

Tanto foi assim que a busca não logrou êxito em encontrar qualquer substância entorpecente ou apetrechos que ligassem o acusado ao crime de tráfico de drogas. Consequentemente, o encontro da arma de fogo no domicílio do acusado foi fato

fortuito e inesperado.

Embora em juízo, os policiais militares que atenderam a ocorrência tenham dito que a denúncia que deu causa à busca tenha dado a informação de que o acusado, além de praticar o tráfico de drogas, também armazenava arma de fogo, na fase policial e, portanto, a que deve ser considerada para a aferição de sua validade, nada mencionou acerca do crime de arma de fogo. Divergência esta já destacada no início desta fundamentação.

Considerando, portanto, o encontro fortuito de provas, a validade destas seguirá o mesmo destino da medida que lhe deu origem, ou seja, se válida a medida anterior, válida será essa prova fortuitamente localizada; todavia, se ilícita a medida anterior, inválida também será essa prova fortuitamente localizada.

Mesmo entendimento é esposado pelo STF no julgamento do HC 129.678/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.08.2017), e no STJ no julgamento do AgRg no REsp 1.752.564, Rel. Min. Ribeiro Dantas (5ªT, DJe 23.11.2020).

Assim sendo, no caso em análise, temos que inválida a localização da arma de fogo com numeração suprimida no domicílio do acusado, uma vez que inválida a medida de busca e apreensão realizada pelos policiais.

Nem mesmo a confissão por parte do acusado, no sentido de reconhecer, em juízo, que guardava a arma de fogo apreendida para proteção própria tem o condão de validar a localização da arma, razão pela qual a materialidade do delito atribuído ao acusado resta prejudicada.

Deste modo, pelas provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível se concluir pela responsabilidade penal do acusado, ante o conjunto probatório extremamente frágil e inconsistente.

Nesse sentido, Nelson Hungria assinala que “a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”. (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

É cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, deve existir nos autos provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário, deverá incidir o princípio do in dubio pro reo.

Ademais, o princípio do in dubio pro reo não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Desta forma, a melhor solução é a absolvição por falta de provas, já que o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades e, sem a certeza total e plena da autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, não pode ser proferida a condenação.

Portanto, é de rigor que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, e consequentemente, o réu seja absolvido.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o acusado DANIEL ÉRISON DE SOUSA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação aos fatos descritos na denúncia.

Defiro que o réu aguarde o resultado de eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Também após o trânsito em julgado, remetam-se a arma e munições apreendidas ao Comando do Exército, com autorização para a sua destruição, nos termos do artigo 25, da Lei nº 10.826/2003, por não mais interessarem à persecução penal.

P.I.C.

Santos, 15 de março de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA